



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' תיק: 1/504/2015

מפקח על רישום מקרקעין
ירושלים

ברוכשטוט אמיר 306515008

התובע

- נגד -

הנתבעים

1. יאנה זסלבסקי גוטמן 3042588759

2. גוטמן דניס 323447011

3. שיכמן זאב אבגני 303939052

4. שיכמן אורית 309556215

5. שלום קשאני 024616807 (-ניתן פס"ד חלקי)

פסק דין

עניינו של פסק דין זה בשאלה האם זכות הבעלות בגינה הצמודה לדירה בבית משותף מתפרשת לחלל הרום, ובהתאם- האם בניית מרפסות מעל לגינה זו מהווה את הסגת גבולו של בעל הדירה. כמו כן נדונה הסוגיה האם נוכח בניית מרפסות אלו תפגע זכותו של בעל הדירה פגיעה מהותית.

א. העובדות

1. עסקינן בבית משותף הידוע כגוש 30627 חלקה 29, והממוקם ברחוב נתיב המזלות 56, בשכונת פסגת זאב בירושלים (להלן: "**הבית המשותף**"). בבית המשותף 8 תתי חלקות ו-5 קומות.
2. לבית המשותף תקנון מוסכם מיום 18.2.14 (ראה נספח 3 לכתב התביעה).

3. התובע הוא בעל דירה בקומת הקרקע, הידועה כתת חלקה 1 ושטחה 63.8 מ"ר (להלן: **"דירת התובע"**) לדירה זו צמודה קרקע (גינה) בשטח של 85.75 מ"ר (להלן: **"הגינה"**). דירת התובע ממוקמת בפועל בקומה התחתונה ביותר של הבניין, שתי קומות מתחת לכניסה הראשית לבניין. מסלון דירת התובע קיימת יציאה לגינה.
4. הנתבעים הם בעלי דירות הממוקמות מעל לדירת התובע. הנתבעים 1-2 הם בעלי הדירה הידועה כתת חלקה 5, המצויה בקומה השנייה של הבית המשותף (להלן: **"גוטמן"**), הנתבעים 3-4 הם בעלי הדירה הידועה כתת חלקה 3, השוכנת בקומה הראשונה של הבית המשותף (להלן: **"שיכמן"**). לדירת שיכמן קרקע צמודה (גינה) בשטח של 54 מ"ר. הנתבע 5 הוא בעל הדירה הידועה כתת חלקה 8, הבנויה בקומות השלישית והרביעית של הבית המשותף (להלן: **"קשאני"**).
5. הנתבעים אוחזים בהיתר בנייה לבניית מרפסות זיזיות בצד הדרומי של הבית המשותף, באורך של כ-6 מטר ורוחב של כ-2 מ"ר, ומעל לגינת התובע. רישיון זה אושר לאחר שהתנגדויותיו של התובע בוועדה המקומית ובוועדת הערר נדחו. במסגרת הדיון בוועדת הערר העלה התובע טענה מקדמית אחת ויחידה והיא טענתו לחוסר סמכותה של הועדה לדון בבקשה בשל היעדרם של "תימוכין קנייניים". ועדת הערר דחתה טענה זו, היות ולא מצאה בה ממש.
6. לאחר שטענותיו נדחו בוועדות התכנון, הגיש התובע את התביעה דנן במסגרתה הוא מבקש כי יינתן צו מניעה קבוע שיאסור על הנתבעים לצמיתות להסיג את גבולו בחלל הרום של הגינה, ובכלל זה לאסור על הנתבעים לבנות מרפסות זיזיות או כל בניה אחרת בשטח זה, וכן להורות על הסרת כל מתקן או מבנה (כגון מנועי מזגן או מתקני כביסה) המסיג, לטענתו, את גבולו בחלל הרום כיום.
7. ביחס לנתבע 5 הלין התובע בכתב תביעתו על בקשתו לבנות חדר מחוץ. נושא זה בא על סיומו עת הגיעו התובע וקשאני להסדר, לו ניתן תוקף של פסק דין (ראה הסכמות הצדדים ופסק דין חלקי מיום 8.5.16).
8. התובע הגיש בקשה למתן צו מניעה זמני. במהלך הדיון בבקשה הצהיר ב"כ הנתבעים, עו"ד הכהן, כי **"נמנע מכל בנייה בבית המשותף ובכלל זה בניית מרפסות מעל החצר הצמודה לדירת המבקש וזאת עד למתן החלטה אחרת"**. עם מתן תוקף של החלטה להצהרה זו, לא עמד עוד המבקש על בקשתו לצו מניעה זמני (פרוטוקול הדיון והחלטה מיום 10.1.16).
9. במהלך בירור ההליך הוגשו תצהירי עדות ראשית מטעם הצדדים, התקיים דיון הוכחות ונשמעו בסופו סיכומי הצדדים בעל פה. לאחר שמיעת סיכומי הצדדים, ערכתי ביקור במקום, בנוכחות באי כוח הצדדים וחלק מהצדדים עצמם (התובע והנתבעת 4) וזאת ביום 16.5.16.

ב. עיקרי טענות הצדדים

עיקרי טענות התובע

10. לטענת התובע, זכותו הקניינית בגינה חולשת גם על חלל הרום ומשום כך, בניית המרפסות לדירות גוטמן ושיכמן מעל הגינה מהווה הסגת גבול.
11. התובע מסתמך על הוראות סעיף 11 לחוק המקרקעין התשכ"ט-1969 (להלן: "**החוק**") ועל פסק הדין בע"א 403/73 **בצלאל נ' סימן טוב**, פ"ד כ"ט (1) 41 (להלן: "**פרשת בצלאל**"), שם לטענתו נפסקה הלכה התומכת בעמדתו המשפטית. התובע הפנה בהקשר זה גם לפסקי דין אשר לשיטתו יישמו את קביעות פסק הדין בעניין בצלאל לעיל: ת"א (מחוזי ת"א) 418/98 **יפוח נ' נגיד** (פורסם ב"נבו". ניתן ביום 22.10.02), ע"פ (מחוזי מרכז) 9003-08-09 **הודסמן ואח' נ' פרץ**, (פורסם ב"נבו" ניתן ביום 1.12.09).
12. התובע מאזכר גם את פסק הדין של בית המשפט העליון בעניין גלבורט (ע"א 239/79, **ישראל גלבורט נ' הממונה על המרשם**, פ"ד לד (2) 807 (להלן: "**פרשת גלבורט**"), אשר ניתן לאחר פרשת בצלאל. לטענת התובע, בפרשת גלבורט מדגיש בית המשפט כי נקודת המוצא היא שסעיף 11 לחוק המקרקעין התשכ"ט-1969 (להלן: "**החוק**" או "**חוק המקרקעין**") חל גם ביחס לבתים משותפים, אף כי שביחס לדירות הוא מוחל בשינויים המחויבים.
13. התובע מאבחן בין קביעות פרשת גלבורט לגבי **דירות**- ביחס אליהן נקבע בפרשת גלבורט כי לא ניתן להחיל את סעיף 11 לחוק, לבין חצר צמודה שהיא קרקע- לגביה, לטענתו, חלות הוראות סעיף 11 בדרך המלך, ללא צורך בהתאמה כלשהי.
14. התובע חוזר ומדגיש בסיכומיו כי פרשת בצלאל קבעה הלכה תקפה אשר בית המשפט העליון טרם סטה ממנה עד היום. לטענתו, בנסיבות אלו יש לפעול על פי הוראות סעיף 20 לחוק יסוד: השפיטה ולאמץ את קביעות פרשת בצלאל כהלכה מחייבת. לטענת התובע, אין בנמצא אף כל פסיקה המציעה לסטות מקביעות פרשת בצלאל.
15. התובע טוען כי בתי המשפט אשר קבעו בניגוד לקביעות פרשת בצלאל, עשו כן בניגוד להוראת חוק היסוד ואף מבלי לאזכר כלל את פרשת בצלאל. כך למשל נעשה לטענתו בבית משפט השלום בקריות בת"א 46120-04-13, **קריידמן ואח' נ' ישינסקי ואח'**, [פורסם ב"נבו"] 5.8.13, אשר דן בנסיבות עובדתיות דומות למקרה דנן, וכן בבית המשפט המחוזי ירושלים בע"א 1415/00, **אברהם נ' אזרד**, [טרם פורסם].
16. טענה נוספת אשר נשמעה מפי התובע, היא טענה לפגיעה מהותית בדירתו עקב בניית המרפסות כמבוקש.

17. התובע טוען בהקשר זה כי דירתו היא דירת מרתף, הבנויה שתי קומות מתחת לכניסה הראשית לבניין וככזו היא דירה אפלה מטבעה. לטענתו, יתרון מהותי בדירה הוא הגינה הצמודה לה. נטען כי גינה זו משמשת כמקור האור היחיד של הדירה בשל מיקומה, ולפיכך בניית המרפסות כמבוקש תפגע בחדירת האור לדירתו.

18. בניית המרפסות אף תפגע, לטענת התובע, בפרטיותו ובשקט הקיים היום בדירתו ובגינה הצמודה לה, מצב דברים אשר היווה שיקול עיקרי עת רכש את דירתו.

עיקרי טענות הנתבעים

19. הנתבעים חולקים על כך כי הבעלות בגינה מתפרשת גם לחלל הרום, וכי בניית המרפסות כמבוקש על ידם תהווה הסגת גבול. נטען, כי מסקנה זו אף אינה הרציו אשר נפסק בפרשת בצלאל כנטען על ידי התובע. לטענתם, יש לאבחן את קביעות פרשת בצלאל מעניינינו גם נוכח הטעם כי באותו המקרה הבניה המבוקשת הסבה לפגיעה מהותית מאוד בדירת הנתבע, דבר שאינו מתקיים, לשיטת הנתבעים, בעניינינו. הנתבעים מוסיפים וטוענים כי קבלת גישת התובע עשויה להוביל למצבים אבסורדיים, לפיהם אף נפנוף יד מחלון דירה הממוקמת מעל הגינה תהווה הסגת גבול.

20. לטענת הנתבעים, פרשת גלבורט אליה מפנה התובע דווקא משרתת את עמדתם, שכן עולה ממנה הקביעה כי הבית המשותף אין דינו כדין בעלות רגילה במקרקעין ויש להפעיל שכל ישר ולהחיל שינויים מחויבים. הנתבעים מדגישים כי פסק הדין בפרשת גלבורט מאוחר לפסק הדין בפרשת בצלאל, ובא לאחר שבתי המשפט כבר "צברו ניסיון" כיצד יש לנהל בתים משותפים לאור חוק המקרקעין, אשר היה רק בחיתוליו בזמן שניתן פסק דין בצלאל בשנת 1973.

21. הנתבעים סומכים ידיהם על הוראות סעיפים 53 ו-55 לחוק, ומדגישים כי מכוחם יש להחיל את הוראות חוק המקרקעין על דירות בבית משותף בשינויים המחויבים. לשיטתם, חלק מהשינויים המחויבים הם שלא להחיל כפשוטן וכלשונן את הוראות סעיף 11 על דירות וחצרות המוצמדות להן בבית משותף.

22. הנתבעים חולקים על טענת התובע כי הבניה המבוקשת על ידם תסב לו פגיעה מהותית. לטענתם, ככל שקיימת פגיעה בדירת התובע היא פגיעה מזערית, וכלל איננה עולה כדי פגיעה מהותית כנדרש בחוק.

23. הנתבעים מדגישים כי גם לדברי התובע כמות האור החודרת לדירתו עד השעה 12:00 היא מזערית ומהשעה 12:00 ואילך אין חולק כי ממילא לא נכנס אור שמש לדירתו. לטענתם, התובע כלל לא הוכיח טענותיו ביחס לפגיעה באור השמש וכי אי הגשת חוות דעת מומחה מטעם התובע בנושא זה, פועלת לחובתו.

ג. דיון והכרעה

24. לצורך ההכרעה בהליך דנן, יש להידרש לשתי שאלות: **האחת**, האם הבעלות בגינה הצמודה לדירה בבית משותף מתפשטת גם לחלל הרום שמעליה. כמו כן יש לדון בשאלה נוספת והיא האם בניית המרפסות המבוקשת מעל לגינה תסב לדירת התובע פגיעה העולה כדי פגיעה מהותית.

המסגרת המשפטית- מהו היקף התפרשותה של זכות הקניין בחצר צמודה בבית משותף?

25. אפתח בהוראות החוק הרלוונטיות לעניינינו.

26. סעיף 11 לחוק, המצוי בפרק ג' לו, מורה כך:

" עומק וגובה

הבעלות בשטח של קרקע מתפשטת בכל העומק שמתחת לשטח הקרקע, בכפוף לדינים בדבר מים, נפט, מכרות, מחצבים וכיוצא באלה, והיא מתפשטת בחלל הרום שמעליו, אולם, בכפוף לכל דין, אין בכך כדי למנוע מעבר בחלל הרום"

27. פרק ו' לחוק שעניינו "בתים משותפים", מונה, בין היתר, את סעיפים 53 ו-55 הקובעים כך:

" 53. כל הוראה בחוק זה, וכל דין החל על מקרקעין, יחולו גם על דירות בבית משותף, בשינויים המחוייבים; ומקום שמדובר ברישום בפנקסי המקרקעין, רואים אותו כאילו מדובר ברישום בפנקס הבתים המשותפים.

55. (א) לכל דירה בבית משותף צמוד חלק בלתי מסוים ברכוש המשותף של אותו בית משותף.

(ב) עיסקה בדירה תחול גם על החלק ברכוש המשותף הצמוד אליה, ואין תוקף לעסקה ברכוש המשותף בנפרד מן הדירה; אין בהוראה זו כדי למנוע פעולה הבאה להקטין או להגדיל את שטח הקרקע שברכוש המשותף.

(ג) בעלי הדירות רשאים לקבוע בתקנון, כמשמעותו בסימן ג' לפרק זה (להלן - התקנון), שחלק מסוים של הרכוש המשותף יהיה צמוד לדירה פלונית, ובלבד שלא יקבעו זאת ביחס לחדרי מדרגות, מעליות, מקלטים ומיתקנים המיועדים לשמש את כל בעלי הדירות; הוצמד חלק מסוים מהרכוש המשותף לדירה פלונית, לא יחולו עליו הוראות פרק זה בנוגע לרכוש המשותף, ודינו לכל דבר כדין הדירה שאליה הוצמד" (הדגשות שלי- י.ע.ש).

28. הנה כי כן, סעיף 11 לחוק מורה כי הבעלות בקרקע מתפשטת הן לעומק והן לגובה הקרקע. סעיף זה מצוי בגדרי פרק ג' לחוק, שאינו דן בבתים משותפים. סעיף 53 לחוק, השוכן בפרק ו' הדן בבתים משותפים, מבהיר למעשה כי יש להחיל את הוראות סעיף 11 על בעלות בבתים משותפים "בשינויים המחויבים" בלבד, ולא ככתבו וכלשונו. סעיף 55 לחוק מוסיף ומבהיר, כי דינה של הצמדה כדין הדירה אליה הוצמד.

29. פסק הדין הראשון ממנו ניתן ללמוד לסוגיה דנן הוא פסק הדין עליו נסמכו עיקרי טיעוניו של התובע- פסק הדין בפרשת בצלאל. פסק דין זה ניתן בשנת 1973, שנים ספורות לאחר חקיקתו של חוק המקרקעין. במסגרת אותה פרשה, הובא לפני בית המשפט העליון מקרה בו נדון בית משותף אשר טרם נרשם ככזה. המשיבים שם, שדירתם שכנה מעל לדירת המערערים, ביקשו להרחיב את דירתם על ידי בניית הרחבה לדירתם הכוללת גג אשר יבלוט מן הקיר בהיקף של שישה מטרים כך שלא תהא עוד גינה גלויה לשמש. כב' השופט כהן החיל את הוראת סעיף 11 גם על אותו המקרה ומשום כך הגיע לתוצאה כי אכן הבניה המבוקשת על ידי המשיבים תהווה הסגת גבול (הממשק בין הוראות סעיף 11 להוראות סעיפים 53 ו-55 לחוק המקרקעין לא נדון במסגרת פסק דין זה). בהקשר זה החיל השופט כהן את הגדרת "המקרקעין" בסעיף 11 על סעיף 29 לפקודת הנזיקין [נוסח חדש] הדן ב"הסגת גבול במקרקעין". כב' השופט ברנזון, גם הוא קיבל את הערעור אולם מטעמים אחרים מאלו של השופט כהן. השופט ברנזון לא השתית את ממצאיו על הוראת סעיף 11 לחוק, כי אם על התקיימותה של עוולת המטרד ועוולת ההפרעה לאור השמש, לפי סעיפים 44 ו-48 לפקודת הנזיקין [נוסח חדש]. השופט מני אימץ את הטעמים המפורטים הן בפסק דינו של השופט ח. כהן והן בפס"ד דינו של השופט ברנזון.

30. פסק דין מאוחר יותר שיצא מידי בית המשפט העליון ונוגע גם הוא לסוגיה דומה, הוא פסק הדין בפרשת גלבורט (ניתן בשנת 1979), גם לו היה שותף השופט כהן. באותו מקרה טען המערער כי גג של מבנה חדש שהוקם על ידי המערער על גבי שטח הגג שהוצמד לדירה מסוימת שבתוך בית משותף, ייחשב גם כן לשטח הצמוד לדירה האמורה. בית המשפט העליון דחה את הערעור (כב' השופט שמגר בהסכמת כב' השופטים כהן ולנדוי). בהתייחסו להוראת סעיף 11 ולמסגרת תחולתו על בעלות בבית משותף, אמר כב' השופט שמגר את הדברים הבאים:

" אין אפשרות ליישם את האמור בסעיף 11 לקושיה שבפנינו. סעיף 53 לחוק קובע, מפורשות, כי כל הוראה בחוק הנ"ל וכל דין החל על מקרקעין יחולו גם על זירות בבית משותף, אך זאת בשינויים הנובעים מן העניין. ממילא גם ההוראות של סעיף 11 שצוטט לעיל יכולות להיות מיושמות לדירות בבית משותף רק בשינויים הנובעים מן העניין. כך ברור, למשל, שההוראה בעניין התפשטותה של הבעלות בכל העומק שמתחת לקרקע (קרי, לפי הטענה, גם מתחת לדירה) אינה ישימה כלל, שהרי בעלות בדירה בקומה ב', למשל, אינה מקנה מיניה וביה גם בעלות בכל מה שמתחתיה - ודירה אחרת בכלל זה - בכל העומק. בדומה לכך, אין בעלות בחלל הרום יכולה להיות מותאמת לדירה בקומה א' אשר מעליה יש דירה בקומה ב'. אולם עיקרו של דבר, יש לבחון את נושא הבעלות בדירה על-פי מהות יחסי הגומלין עם יתר בעלי הדירות בבית המשותף. זה אחרון בנוי על חלוקה מוחשית של הרכוש לדירות, אך כולל בכל מקרה בהכרח גם רכוש משותף, שקיומו נובע בדרך הטבע מבנייתו של הבית המשותף (למשל, בכל מקרה - המסד). כל גריעה מן

הרכוש המשותף חייבת להיות מפורשת וברורה ואין מפרשים אותה בהרחבה אלא בדיוקנות ובדיוק ואין לנהוג בפרשנות מקילה ובהסקת מסקנות מכללא בכל הנוגע להגדרת תחומי השיתוף מחד גיסא, ותחומי הפרט, מאידך גיסא

31. הנה כי כן, פסק הדין בעניין גלבורט שלל את תחולת סעיף 11 לחוק על שטחים המוצמדים לדירות בבתי משותפים באופן גורף. כב' השופט שמגר כאמור, אף הדגיש בפסק דין זה עד כמה גריעה מן הרכוש המשותף חייבת להיות מפורשת וברורה וכי יש לפרשה בדיוקנות.

32. על אף שפסק הדין בפרשת בצלאל ניתן כבר לפני למעלה מ-40 שנה, עלה בידי התובע להפנות מותב זה לפסק דין בודד אשר יישם את קביעותיו במהלך השנים, באופן בו נקבע כי הבעלות בגינה הצמודה לדירה בבית משותף מתפרשת גם לחלל הרום (ת.א. (מחוזי ת"א) 418/98 **יפרח נ' נגיד**, [פורסם בנבו] ניתן ביום 28.10.02). מעבר לכך, עיון בפסק דין זה מעלה כי יש לפרש את קביעותיו ככונות באופן פרטני לנסיבות אותו מקרה שנדון שם נוכח ההוראות בתקנון המוסכם הייחודיות לאותו בית משותף, וספק אם יש ללמוד מהן על עניינינו.

33. פסק דין אחר אליו הפנה ב"כ התובע הוא ע"פ (מחוזי מרכז) 9003-08-09 **הודסמן ואח' נ' פרץ**, (פורסם ב"נבו" ניתן ביום 1.12.09). פסק דין זה עניינו בערעור על החלטה בבקשה לצו ביזיון בית משפט. באותה פרשה יושם סעיף 11 לחוק במקרקעין המחולקים למגרשים, כאשר קיים הסכם שיתוף בין הצדדים, ואין מדובר כלל בבית משותף. לפיכך, אין בו כל רלוונטיות לעניינינו.

34. מנגד, ניתן לאתר פסיקה אשר ממנה עולה, בין היתר בהסתמך על קביעות פרשת גלבורט, כי הוראת סעיף 11 אינה חלה על חלל הרום של חצר צמודה בבית משותף.

35. כך למשל, בע"א (מחוזי ירושלים) 1415/00, **אברהם נ' אזרד** (לא פורסם. להלן: "**פרשת אזרד**") נדון מקרה בו המשיב היה בעל הזכויות בדירה בקומת הקרקע, לרבות חצר הצמודה לדירתו, והמערערים בעלי זכויות בקומה השנייה של הבית המשותף. המערערים בנו מרפסת תלויה בגודל של 6 מ"ר מעל החצר הצמודה לדירת המשיב, והמשיב התנגד לבנייתה. בית המשפט המחוזי לא מצא כי זכויותיו הקנייניות של המשיב בחצר מצדיקות למנוע מהמערערים לבנות את המרפסות התלויות.

36. כך גם בת"א (שלום קריות) 46120-04-13 **קריידמן ואח' נ' ישינסקי ואח'** (פורסם ב"נבו". ניתן ביום 5.8.13), נדון מקרה דומה בבית משותף, בו בעל חצר צמודה ביקש למנוע בניית מרפסות מעל לחצר בטענה של הסגת גבול לחלל הרום. בפסק דין מפורט ומנומק דחה כב' השופט מוחמד עלי את טענתו של בעל החצר. השופט עלי הסתמך בפסיקתו, בין היתר, על הוראות סעיפים 53 ו-55 לחוק המקרקעין וכן על קביעותיו של בית המשפט העליון בפרשת גלבורט, והחשיבות הקיימת להחלת הוראות חוק המקרקעין על תחום הבתים המשותפים ב"שינויים המחויבים". לפיכך נקבע כי החלת השינויים המחויבים של סעיף 11 לחוק על בית משותף מחייבת לקבוע כי הבעלות בשטח המוצמד לדירת התובעים מסתיימת במפלס תקרת דירתם. בין היתר, עמד השופט על התוצאה האבסורדית העולה להתרחש לו יוחל סעיף 11 לחוק על חצר צמודה בבית משותף-

"דומה כי המסקנה לעיל מתיישבת עם הגיונם של הדברים, שכן מסקנה אחרת יש בה כדי להוליך לתוצאה אבסורדית. נטול למשל בית משותף בן עשר קומות, ולקומת הקרקע שבו הוצמדה גינה. לפי טיעונם של התובעים, הדייר בקומה העשירית אינו זכאי כלל להרחיב את דירתו (על ידי הוספת מרפסת למשל, כמובן בהתקיים שאר התנאים לכך) שכן הרחבה שכזו אינה ברכוש המשותף אם כי בקניינו של הדייר מקומת הקרקע. ואם באותה דוגמה עסקינן; האם הדייר בקומה החמישית אינו זכאי להרחיב את דירתו על ידי הוספת מרפסת המקבילה למרפסת של הדייר בקומה השניה? נראה כי התשובות לכך ברורות" (ראה בפסקה 26 לפסק הדין).

37. התייחסות לסוגיה זו, קיימת גם בספרו של המלומד א. אייזנשטיין (יסודות והלכות בדיני מקרקעין, חלק שלישי, עמ' 124 ואילך - להלן "אייזנשטיין"). נוכח הייחודיות של זכות הקניין בבית משותף, אף אייזנשטיין סבור כי כפי שאין להחיל את סעיף 11 על דירות, כך גם אין להחיל על שטחי הצמדה בבית משותף, לרבות חצר צמודה-

"... אנו סבורים שהבעלות על שטח הצמדה מכל סוג שהוא, אינה מתפשטת לגובה ולעומק, אלא אם נאמר הדבר במפורש בתקנון המוסכם. דבריו של השופט שמגר בפס"ד גלבורט ש"אין לראות ברכוש צמוד אלא את מה שהוצמד מפורשות" יפים לא רק לגבי שטח הצמדה של גג אלא גם לכל שטח הצמדה. לדעתנו, הבעלות על שטח הצמדה של קרקע נפסקת במפלס האוויר של הדירה הנמצאת מעליו, כל עוד לא נקבע מפורשות אחרת, בהסכמת כל בעלי הדירות. אם לא נאמר כן, נקבל תוצאה אבסורדית שבעלי דירות בקומות העליונות לא יהיו רשאים להתקין, למשל, מזגנים בקיר החיצוני של הבניין הנמצא מעל שטח ההצמדה, למרות שהאסיפה הכללית החליטה להרשות את ההתקנה. סעיף 53 לחוק קובע אמנם כי "כל הוראה בחוק זה, וכל דין החל על מקרקעין, יחולו גם על דירות בבית משותף", אולם בהמשך הסעיף נאמר כי החלתו תהיה "בשינויים המחויבים". אין ספק שהמחוקק לא התכוון להחיל את סעיף 11 לחוק על שטחי הצמדה בבית משותף".

38. על ייחודיותה של זכות הקניין בבית משותף, יפים גם דבריו של בית המשפט העליון ברע"א 1462/10, עטייה נ' שגיא (פורסם בנבו. ניתן ביום 2.8.12) - בפסקה 14 (להלן: "עניין עטייה")-

"התפישה היא שזכויות הקניין בבית המשותף עוצבו מלכתחילה באורח שונה מזה של זכות בעלות במובן ה"קלאסי" (שהוגדרה כזכותו של אדם לעשות ולא לעשות בקניינו כרצונו), כך שבעלי הדירות מוותרים על חלק מהאוטונומיה הקניינית הקנויה להם ומקנים חלק מזכויותיהם למסגרת השיתופית המתמשכת והקבועה (עניין צודלר, בעמ' 562-564). דפוס זה מצר את תוכנה של זכות הקניין הנפרדת ברכוש המשותף כדי להתאימה לתכונות הייחודיות של הבית המשותף. כך, בנסיבות מסוימות ניתן להגביל את יכולתו של המיעוט לכפות את רצונו על הרוב, גם אם משמעות הדבר היא פגיעה בזכויותיו הקנייניות של המיעוט ברכוש המשותף. לאורך ההיסטוריה החקיקתית של חוק המקרקעין ניתן להבחין בשינויי חקיקה שעניינם במזעור וצמצום יכולתו של מיעוט בעלי הדירות בבית המשותף לסכל את החלטות הרוב, אפילו פוגעות החלטות אלו בזכויותיו ברכוש המשותף (ויסמן-דיני קניין, בעמ' 349-351)".

39. ואכן, כפי שצוין בעניין עטיה, מאז שניתן פסק הדין בפרשת בצלאל חלו שינויים חקיקתיים משמעותיים. כך למשל, חקיקתו של חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו אשר העלה את זכות הקניין למעמד חוקתי על חוקי. כך גם שינויי חקיקה שנעשו בחוק המקרקעין עצמו. אחד מהם, הוא תיקון 18 (ס"ח 1518 תשנ"ה, עמ' 188, ה"ח 2303 התשנ"ד עמ' 629), במסגרתו נקבע חריג, המתייחס באופן פרטני לשינוי ברכוש המשותף **על דרך של הצמדתו לצורך הרחבת דירה פלונית**. לגבי שינוי או פגיעה במובן זה ברכוש המשותף, דורש המחוקק הסכמה ברוב מופחת מזה הנדרש לצורך הצמדת רכוש משותף לדירה פלונית, ככלל. יתרה מכך, המחוקק אף קובע הסדרים פרטניים באשר לבעל דירה שנפגע מקבלת ההחלטה "פגיעה מהותית" -זאת על דרך מתן סמכויות רחבות למפקח להורות על שינוי, ביטול או התנאת ההחלטה בתנאים, וכן על תשלום דמי איזון לנפגע (ראה בסעיף 71 לחוק).

40. בדברי ההסבר להצעת חוק המקרקעין (תיקון מס' 19) (שינוי הרוב הדרוש לשינויים ברכוש המשותף) התשנ"ה-1994 (הצעות חוק, התשנ"ה, עמ' 114) הובהר כך-

"מטרת הצעת חוק זו היא לאפשר שינויים ברכוש המשותף בבית המשותף, במטרה למצוא פתרונות לבעיית צפיפות המגורים של משפחות רבות בדרך של הרחבת דירות קיימות או לבעיית צפיפות אוכלוסין השכיחה באזורים מסוימים בארץ, בדרך של בניה על הרכוש המשותף. על פי המוצע בסעיף 71 יהיו רשאים רוב בעלי הדירות ששני שלישים מהרכוש המשותף צמודים לדירותיהם, להחליט על שינויים ברכוש המשותף, אם מטרת השינוי היא הרחבת דירה קיימת אחת, או יותר, בבית המשותף. כיום, על פי הקבוע בסעיף 62 לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969, החלטה זו טעונה הסכמת כל בעלי הדירות בבית המשותף. דרישה זו מהווה מכשול מהותי ומוצע לשנותה. יחד עם זאת מוצע לקבוע במפורש מנגנון לפיצוי בעל דירה שנפגע באופן מהותי בדרך של תשלומי איזון"

41. הנה כי כן ניכר כי מגמת המחוקק היא להקל על ביצוע הרחבות בבתים משותפים (ויוזכר כי כבר נפסק זה מכבר כי גם בניית מרפסת היא בגדר "הרחבה" – ראה בפרשת אזרד לעיל), ולנטייה זו יש ליחס משקל בפרשנות החלת סעיף 11 על בית משותף.

מן הכלל אל הפרט

42. בשים לב לסקירת המסגרת המשפטית לעיל, הגעתי לכלל מסקנה כי אין להחיל את סעיף 11 לחוק על נסיבות המקרה דנן.

43. יש לזכור כי קביעות פרשת בצלאל ניתנו במסגרת דיון בעילת תביעה נזיקית. לאחר הינתנה, צומצמה כאמור פסיקה זו במסגרת פסק דינו של בית המשפט העליון בפרשת גלבורט, ואף בפסיקת הערכאות הנמוכות יותר ניתן משקל של ממש לתמורות שחלו בחוק ברבות השנים ובתוך כך לאופן החלת סעיף 11 ב"שינויים המחויבים" בכל הנוגע לבתים משותפים. בשים לב לכל אלו, אינני סבורה כי יהא זה מוצדק או ישים להחיל

את הוראת סעיף 11 כלשונה על חצר צמודה בבית משותף. על רקע זה נראה כי קביעות אלו נכונות למסגרת נסיבותיו הפרטניות.

44. שותפה אני לדעתו של המלומד אייזנשטיין, ולמסקנתו של בית המשפט המחוזי בפרשת אזרד ובית משפט השלום בעניים קריידמן. הבעלות בדירה בבית משותף חלה משטח הרצפה ועד שטח התקרה. הדברים נכונים גם לגבי חצר צמודה, אשר הבעלות בה מסתיימת בטווח התקרה של הדירה לה היא מוצמדת. החלטת סעיף 11 על חצר צמודה בבית משותף עשויה להוביל לתוצאות אבסורדיות, כמו למשל מניעת הרחבת כלל הדירות בית משותף אל שטח המצוי מעל לחצר צמודה, אף אם מדובר בהרחבה מינורית הבנויה מספר רב של קומות מעל לחצר הצמודה. אף ב"כ התובע ציין, בהגנותו, כי ספק אם קביעות פרשת בצלאל חלות על בתים משותפים בעלי קומות רבות (ראה פרוטוקול מיום 8.5.16 בעמ' 18 שורות 22-24).

45. על רקע תכליתו של תיקון 18 לחוק והחשיבות שהקנה המחוקק להרחבת דירות קיימות (קל וחומר היום, על רקע "משבר הדירה"), אינני סבורה כי יש להחיל את סעיף 11 לחוק על גינה צמודה לדירה בבית משותף, כפי שמבוקש בתביעה זו.

46. יתרה מכך. לשם הוצאת חלק מהרכוש המשותף יש צורך בהוראה ברורה ומפורשת בתקנון הבית המשותף, ואין ליתן פרשנות מרחיבה לסוגיה זו, העלולה להוביל לפגיעה בלתי מידתית בזכויות הקניין (ראה למשל פרשת עטיה לעיל וכן ע"א 5043/96 גלמן ואח' נ' הררי-רפול ואח', פ"ד נד(3) 389- להלן: "פרשת גלמן").

47. נותר לבחון האם במסגרת התקנון המוסכם של הבית המשותף עוגנו הוראות מהן ניתן ללמוד על זכותו של התובע גם בחלל הרום של הגינה.

48. כידוע, תקנון מוסכם הוא בגדר הסכם שנערך בין בעלי הדירות בבית המשותף, ולו מעמד קנייני (ראה א. אייזנשטיין, "יסודות והלכות בדיני מקרקעין", חלק ג' תשס"א, בעמ' 132-133). נפסק כי ככל הסכם, גם את התקנון המוסכם יש לפרש לפי אומד דעת הצדדים. הוצאה של רכוש משותף והצמדתו לדירה יש לעגן באופן מפורש בתקנון המוסכם. כל הוראה הנוגעת להצמדה יש לפרש בצמצום וזאת נוכח העובדה כי היא מעגנת בחובה ויתור על זכות קניינית (ראה בפרשת גלמן).

49. עיון בתקנון המוסכם של הבית המשותף מעלה כי נקבעו בו הוראות לעניין הצמדות של שטחי קרקע לחלקות משנה 1-4. ביחס לחלקה 1, היא דירת התובע, תיאור ההצמדה הוא "קרקע", ומצוין שטחו (85.75 מ"ר). אין בתקנון כל הוראה מפורשת לפיה הגינה הצמודה לדירת התובע מתפרשת עד רום הרקיע.

50. אשר על כן, מצאתי לנכון לדחות את טענת התובע כי בבניית המרפסות על ידי הנתבעים כמבוקש יש משום הסגת גבולו, שכן אין בעלותו בגינה מתפרשת אל עבר חלל הרום.

51. משהגעתי לכלל מסקנה זו, יש להמשיך ולבחון את טענתו הנוספת של התובע ולפיה בניית המרפסות הזיזיות כמבוקש על ידי הנתבעים תוביל לפגיעה מהותית בדירתו.

על הרחבת דירה ופגיעה מהותית

52. רכוש משותף מוגדר בסעיף 52 לחוק כך-

"רכוש משותף" - כל חלקי הבית המשותף חוץ מן החלקים הרשומים כדירות, ולרבות הקרקע, הגגות, הקירות החיצוניים, המסד, חדרי המדרגות, מעליות, מקלטים, וכן מיתקני הסקה או מים וכיוצא באלה המיועדים לשמש את כל בעלי הדירות או מרביתם אפילו הם בתחומי דירה מסויימת.

53. ככלל, כל שינוי ברכוש המשותף כמוגדר לעיל, על דרך הצמדתו לדירה פלונית, דורש את הסכמת כל בעלי הדירות. כלל זה קבוע בסעיף 62(א) סיפה לחוק - "אין לקבוע הצמדה של חלק מסוים מהרכוש המשותף לדירה פלונית אלא בהסכמת כל בעלי הדירות".

54. חריג לכלל זה קבוע בסעיף 71ב(א) לחוק, אשר הוסף כאמור, במסגרת תיקון 18 ודן ב"הרחבה" -

"על אף הוראות סעיף 62(א) סיפה, או סעיף 12(ב) לתקנון המצוי שבתוספת, רשאים מי שבבעלותם שלושה רבעים מהדירות ושני שלישים מהרכוש המשותף צמוד לדירותיהם, להחליט בדבר הוצאה של חלקים מסוימים מהרכוש המשותף והצמדתם לדירה פלונית, לשם בניה שמטרתה הרחבת אותה דירה, וכן להחליט בדבר חלוקת זכויות הבניה הנדרשות לצורך זה, ואולם, היה נושא ההחלטה כאמור הרחבת דירה פלונית אחת או יותר לשם בניית מרחב מוגן דירתי או מרחב מוגן קומתי, רשאים להחליט על כך מי שבבעלותם שישים אחוזים מהדירות".

55. המונח "הרחבה" מוגדר בסעיף 71א לחוק - "הגדלה של שטח דירה קיימת בבית המשותף שניתן לקבל לגביה היתר בניה לפי תכנית בת-תוקף".

56. על המונח "הרחבה" נאמר כי-

"כל הגדלה המהווה המשך טבעי של הדירה... יכולה הרחבה להיות אנכית, כגון, בניה על גג הבית, שהוא רכוש משותף וחיבור התוספת שנבנתה לדירה שמתחתיה. ההרחבה יכולה להיות גם אופקית, כגון בניית מרפסת או סגירתה, בניית פרגולה, בניה בחצר וחיבור התוספת שנבנתה לדירה קיימת בקומת הקרקע. התנאי להרחבה הוא כי ההרחבה תהא מתוך דירת המבקש" (ר': א. אייזנשטיין, יסודות והלכות בידי מקרקעין חלק ג', 222, ההדגשה לא במקור; ר' גם הפסיקה המובאת שם).

57. בפסיקה נקבע כי גם בניית מרפסת "תלויה" מהווה "הרחבה" כמשמעותה בסעיף 71ב לחוק (ראה: ע"א (ירושלים) 1415/00, **אברהם נ' אזרד** (לא פורסם, ניתן ביום 4.7.01. להלן: "**פרשת אזרד**", עש"א (חי) 50945-05-12, **מיכל ברק נ' דבורה קרש** [פורסם ב"נבו", 19.5.13]).

58. סעיף 71ב(ד) לחוק מוסיף ומעניק סמכויות רחבות למפקח על רישום מקרקעין המגיעות אף כדי ביטול החלטה שהתקבלה לפי סעיף 71ב(א) בתנאים מסוימים. בין היתר, רשאי המפקח להפעיל סמכויות אלו אם נוכח כי בעקבות החלטה המאשרת את ביצוע ההרחבה נפגעה זכותו של בעל דירה "**פגיעה מהותית**".

(ד) **ראה המפקח כי נפגעה זכותו של בעל דירה, פגיעה מהותית, או כי טעה שמאי המקרקעין שנקבע כאמור, רשאי הוא להורות על ביטול ההחלטה שנתקבלה, לשנותה או להתנותה בתנאים, הכל כפי שימצא לנכון, בין בדרך של תשלומי איזון ובין בדרך אחרת, וכן רשאי הוא ליתן הוראות לעניין סדרי הרישום בלשכת רישום המקרקעין.**

59. מהי, אם כן, **פגיעה מהותית**, בה דן סעיף 71ג(ד) לחוק המקרקעין? המלומד א. אייזנשטיין מפרש זאת כך:

"**פגיעה מהותית**" – בהקשר לסעיף 71ג(ד) הנ"ל, הינה פגיעה מתמדת ומתמשכת הגורמת לבעל דירה סבל פיזי או נפשי שאדם סביר לא היה מוכן להשלים עמו גם תמורת פיצוי כספי הולם. כגון, הסתרת אור, אוויר, נוף, מטרד מתמשך וכיו"ב... (ראה: א. אייזנשטיין, יסודות והלכות בדיני מקרקעין, חלק שלישי, עמ' 218).

60. בע"א 133/97, **יוסוביץ נ' חי ואח'** (לא פורסם – להלן: "**עניין יוסוביץ**"), נדון המונח "**פגיעה מהותית**", בהקשר של בניית מעלית, כאמור בסעיף 59(א)(2) לחוק המקרקעין. נקבע שם כך:

"...הגב' חי רכשה את דירתה כאשר היו בה אוורור טבעי ותאורה טבעית, באותן מגבלות פיזיות שבהן נבנתה הדירה מלכתחילה. אולם ברור שהדירה נבנתה ונרכשה כדירה שיש בה תאורה ואוורור טבעיים, גם אם איכותם לא הייתה מושלמת. לא בכדי עמדה המפקחת על הפגיעה המשמעותית ביותר הן במקור האור והן במקור האוויר לדירה, כתוצאה מעבודות ההתקנה של המעלית, ואנו תמימי דעים אתה לגבי חומרת הפגיעה באיכות החיים בדירה (גם אם לא עשתה שימוש במילים אלה דווקא). אנו סבורים כי הירידה הצפויה באיכות החיים בדירה (בהיבט של אוורור ותאורה טבעיים) מהווה "**פגיעה מהותית**" בדירתה של חי, ועל-כן לא התמלאו שני התנאים הקבועים בסעיף 59(א) לחוק המקרקעין לשם קבלת החלטה באסיפה הכללית על התקנת מעלית..."

61. נפנה לבחינת נסיבות המקרה דנן.

62. במקרה הנדון לא נטען כי ההחלטה על בניית המרפסות אינה נהנית מהרוב הקבוע בסעיף 71ב לחוק. טענת התובע היא כי בניית המרפסות הזיזיות כמבוקש תסב לדירתו פגיעה מהותית, נוכח הפגיעה בחדירת אור השמש ובפרטיות, הכרוכה בה. התובע מדגיש כי רכש את דירתו כפי שהיא וללא מרפסות כלשהן מעל לגינה, וכי שינוי מצב זה עשוי לפגוע בו באופן מהותי.

63. על אף שבנסיבות מסוימות הכירה הפסיקה בכך שפגיעה בכמות האור לדירה עשויה להיות ל"פגיעה מהותית", לא מצאתי כי בנסיבות המקרה הנדון בניית המרפסות הזיזיות אכן תפגע בזכויות התובע באופן שזוה.

64. בכל הנוגע לטענה בדבר פגיעה בחדירת אור השמש הציג התובע תמונות (ראה מוצג ת/1, נספח 8 לתצהיר התובע וכן נספח 1 לבקשת התובע להוספת ראייה מיום 18.5.16 - להלן: "**התמונה הנוספת**"). מתמונה ת/1 ניתן להתרשם כי אור שמש מגיע לשטח הגינה הסמוך לכניסה לסלון דירת התובע, על פי עדות התובע בעיקר עד השעה 12:00 (ראה פרוטוקול הדיון מיום 8.5.16, עמ' 5 שורות 9-2). מנספח 8 לתצהיר התובע ומהתמונה הנוספת ניתן ללמוד כי אור היום לא חודר לדירת התובע, אלא במעט מאוד ובשעה מסוימת מאוד של היום (בסביבות השעה 10:00 בבוקר - ראה בסעיף 9 לבקשת הנתבע להוספת ראייה, שכן נטען כי התמונה צולמה כשעה לפני הביקור שנערך במקום). ניתן אף לומר כי ככל שקיימת חדירת שמש לדירת התובע היא מינורית ומגיעה לכדי כתם צר הסמוך מאוד לפתח היציאה מדירת התובע לגינה.

65. על מנת לבחון היטב את טיבה של דירת התובע והגינה ואת כמות אור השמש החודרת לדירה או הקיימת בגינה, ערכתי לאחר שמיעת סיכומי הצדדים ביקור במקום. הביקור החל בשעה 11:00 וזאת נוכח דברי התובע במהלך הדיון שהתקיים ביום 8.5.16, כאשר במענה לשאלתי "באילו שעות יש לך הכי הרבה אור?" השיב כי מדובר בשעות שבין 11:00-12:00 (ראה פרוטוקול הדיון מאותו מועד, עמ' 6 שורות 13-14).

66. בביקור במקום נוכחתי לראות כי אכן דירת התובע חשוכה מטבעה (בשים לב למיקומה כשתי קומות מתחת לכניסה הראשית לבית המשותף). בזמן הביקור ראיתי עוד כי דווקא שטח הגינה הסמוך לפתח הכניסה לסלון דירת התובע מוצל ברובו ואילו חלק הגינה שהוא שטוף שמש בשעה זו מרוחק מפתח הכניסה לסלון. בזמן הביקור לא ראיתי כל חדירת אור כלשהי, אף לא מעטה, אל סלון דירת התובע. חדירת האור נפסקה למעשה על סף דלת הכניסה מהגינה אל הסלון.

67. אמנם, מהתמונה הנוספת שצולמה זמן קצר לפני הביקור במקום עולה כי מעט אור אכן נכס לסלון דירת התובע בשעה מוקדמת משעת הביקור, אולם גם כאן מדובר בכמות אור זניחה (ובנסיבות העניין אף לזמן קצר בלבד).

68. בשים לב למכלול הנתונים לא התרשמתי כי בניית המרפסות מעל דלת הכניסה מגינת הנתבע לסלון, כמבוקש, תסב לתובע **פגיעה מהותית** מבחינת חדירת אור שמש. ראשית, אור השמש כמעט ואינו חודר כלל לדירת התובע ואם חודר הרי זה מעט מאוד ולזמן קצר בהחלט במהלך היום. שנית, מצאתי כי גם אם יש ממש בטענת התובע בנוגע לכך שהמרפסות תצלנה על הגינה, הרי שממילא בשעה בה לטענת התובע עצמו, הדירה מוארת ביותר (11:00 בבוקר לערך) חלק הגינה המצוי מתחת למקום בו מיועדות להיבנות המרפסות - כבר מוצל באופן טבעי. יתר הגינה היא זו שטופת השמש, והיא גם תישאר כך לאחר בניית המרפסות שכן היא מרוחקת מאוד מהמקום המיועד לבניית המרפסות.

69. התובע לא הגיש כל חוות דעת מומחה המעידה כי ההשפעה שתהיה לבניית המרפסות על הצללת הגינה תהא משמעותית יותר. בהקשר זה לא למותר לציין כי גם התובע עצמו, בתצהירו, הפנה לפסיקה לפיה הפגיעה באור השמש היא עניין שבמומחיות (ראה בסעיף 15 לתצהירו). דא עקא, כי כאמור, חוות דעת שכזו לא הוגשה, ומשום כך לא עלה בידי התובע להוכיח את טענותיו לפגיעה מהותית בדירתו.

70. נראה כי גם בחירתו של התובע שלא להעלות את טענותיו בנוגע לפגיעה בחדירת האור או פגיעה בפרטיות במסגרת הדיון במוסדות התכנון, על אף שניתנה לו ההזדמנות לעשות כן, מחלישה במידת מה ממשקלה של הטענה. בהקשר זה יש לציין את החלטת ועדת הערר בה נאמר כי: **"בעניינינו, בחר העורר, גם לאחר שנתנו לו הזדמנויות נוספות, שלא להעלות בפנינו טענות בדבר הסתרת אור השמש וטענות תכנוניות אחרות שניתן היה להעלות נגד אישור הבקשה ונגד אישור ההקלה"** (ראה החלטת ועדת הערר מיום 10.12.15, עמ' 31 פסקה 15).

71. סיכומו של דבר, אף אם קיימת פגיעה מסוימת בחדירת האור לגינה של התובע, לכל היותר מדובר בפגיעה קלה בדירתו. לא מצאתי כי פגיעה זו עולה כדי "פגיעה מהותית" כדרישת המחוקק, המצדיקה, בנסיבות מסוימות, את ביטול ההחלטה המתירה את בניית המרפסות לדירות הנתבעים.

72. בחקירתו הודה התובע כי אינו יכול לאשר שבניית המרפסת המבוקשת על ידי גוטמן תפגע באופן כלשהו בחדירת האור לדירתו, אך טען כי זו תפגע בפרטיותו (ראה פרוטוקול מיום 8.5.16, עמ' 6 שורות 20-23).

73. גם בהיבט של הפגיעה הנטענת בפרטיות, אין בידי לקבל את טענת התובע. מעל לסלון דירת התובע, במיקום בו מיועדות להיבנות המרפסות, קיימים גם היום חלונות של דירות הנתבעים, כך שגם עתה יש באפשרות הנתבעים להשקיף אל המתרחש בגינת התובע, לו יחפצו בכך. במצב דברים זה אינני סבורה כי יהיה בבניית המרפסות משום שינוי משמעותי שיש בו כדי להוביל לפגיעה מהותית.

ד. סוף דבר

74. התביעה - נדחית.

75. בנסיבות העניין, לא מצאתי לנכון לעשות צו להוצאות.

ניתן היום, כ"ב סיון תשע"ו, 28 יוני 2016, בהיעדר הצדדים.

יעל ענתבי-שרון

מפקחת על רישום מקרקעין